

ROSHDI BIN ZAKARIA

lawan

ROSMAWATI BINTI MAHFAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)]

Pada : 3hb Mei 2021 / 21 Ramadhan 1442H

Rayuan No. 10000-028-0133-2019

[Rayuan Terhadap Perintah Hak Jagaan Anak]

Peguam Syarie Pemohon: -

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu ke atas keseluruhan perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam kes no. 10200-028-0702-2018 yang telah diputuskan pada 13/11/2019. Perintah tersebut sepertimana berikut:

- 1.1 *Mahkamah memerintahkan hak jagaan kekal ke atas anak-anak yang bernama Muhammad Ridhwan Azim Roshidi (No k/p : 020717-10-1303) dan Muhammad Raif Imran bin Roshidi (No k/p : 071105-10-1755) (selepas ini disebut sebagai anak-anak tersebut) diserahkan*

kepada Plaintiff (ibu) mengikut peruntukan seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

- 1.2 Defendan (bapa) diberikan hak lawatan dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada minggu kedua (2) dan keempat (4) setiap bulan dengan mengambil anak-anak tersebut bermula jam 7.00 petang hari Jumaat dan memulangkan anak-anak tersebut kepada Plaintiff pada hari Ahad selewat-lewatnya jam 6.00 petang.*
- 1.3 Hak Bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada cuti-cuti persekolahan adalah dibahagikan sama rata antara pihak-pihak.*
- 1.4 Hak bersama dan bermalam diberikan kepada pihak-pihak pada cuti Hari Raya Aidilfitri 1441H bersamaan 2020 diberikan kepada Defendan bermula hari raya pertama hingga hari raya ketiga dengan diambil anak-anak tersebut bermula jam 10.00 pagi hari terakhir puasa dan dipulangkan pada hari raya ketiga jam 6.00 ptang dan Hari Raya Aidil Adha 1441H diberikan kepada Plaintiff sepenuhnya. Pada tahun 2021 Hari Raya Aidilfitri 1442H diberikan kepada Plaintiff bermula hari raya pertama hingga ketiga dan Defendan dibenarkan mengambil anak-anak tersebut pada hari raya ketiga jam 6.00 petang dan dipulangkan hari raya keenam dan Aidil Adha 1442H diberikan kepada Defendan dan seterusnya adalah bergilir-gilir setiap tahun dan ke hadapan.*

1.5 Mahkamah memerintahkan lokasi pengambilan dan penyerahan anak-anak tersebut hendaklah dibuat di tempat tinggal anak-anak tersebut atau lokasi lain dengan persetujuan kedua-dua pihak.

[2] Perayu tidak berpuas hati dengan perintah tersebut, telah memfailkan notis rayuan pada 25/11/2019 dan seterusnya memfailkan alasan rayuannya bertarikh 13/2/2020 dengan memplidkan tiga (3) alasan rayuan seperti di muka surat 138-139 rekod rayuan iaitu :-

- i. Hakim Bicara telah khilaf dari segi hukum Syarak apabila memutuskan menolak tuntutan Defendan (Perayu) pada tuntutan balasnya tanpa dibicarakan.
- ii. Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan kes berdasarkan pilihan anak ketiga dan keempat semata-mata tanpa memberi ruang kepada Plaintiff (Responden) dan Defendan (Perayu) untuk kes dibicarakan dan keterangan pihak-pihak diambil dan ini telah memprejudiskan Defendan (Perayu).
- iii. Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila gagal mengambil kira kewujudan semakan terhadap prosiding kes dan memberikan keputusan kepada Plaintiff (Responden).

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah bernikah pada 21/12/1999 dan telah bercerai pada 19/4/2018 dengan talaq satu. Hasil pernikahan, mereka telah dikurniakan empat (4) orang cahaya mata iaitu:-

Bil	Nama	No k/p
1.	Muhammad Rahimi bin Rashidi	No. k/p : 990105-56-5403
2.	Aisyah Liyana binti Abdul Halim	No. k/p : 001004-10-0645
3.	Ahmad Hafiz Hakimi bin Abdul Halim	No. k/p : 020717-10-1303
4.	Ahmad Hakeem Husaini bin Abdul Halim	No. k/p : 071105-10-1755

“selepas ini dikenali sebagai ‘anak-anak tersebut’”.

[4] Responden telah memfailkan tuntutan hak jagaan terhadap anak-anak tersebut pada 25/10/2018. Semasa kes difailkan, anak-anak tersebut masing-masing telah berumur 19, 18, 16 tahun dan 10 tahun. Responden telah mengemukakan keterangan secara afidavit dan Perayu pula telah memberikan keterangan secara lisan beserta keterangan seorang saksi iaitu Roslizan bin Zakaria.

[5] Selanjutnya, pada 25/7/2019 anak-anak tersebut telah dipanggil untuk ditemu bual oleh Mahkamah bagi mendengar pilihan masing-masing. Mahkamah telah menetapkan 13/11/2019 untuk keputusan sebagaimana di perenggan 1 di atas.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Setelah kami meneliti rekod rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami berpendapat terdapat satu sahaja isu yang perlu kami ulas dan putuskan dalam rayuan ini iaitu **sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dalam membuat keputusan bahawa hak jagaan anak-anak tersebut diserahkan kepada Responden selaku ibu kandung berdasarkan pilihan anak-anak.**

[7] Kami bersetuju **alasan rayuan pertama** Perayu ditolak kerana kami dapati isu berkaitan Tuntutan Balas Perayu telah pun dipertimbangkan oleh Hakim Bicara semasa membuat perintah hak jagaan tersebut. Merujuk kepada Pembelaan dan Tuntutan Balas Perayu bertarikh 13/2/2019 dimuka surat 33-61 Rekod Rayuan, kami mendapati Hakim Bicara telah meraikan Tuntutan Balas Perayu tersebut apabila anak-anak tersebut iaitu anak ketiga dan keempat telah dipanggil membuat pilihan untuk tinggal dengan Perayu ataupun Responden.

[8] Merujuk kepada Alasan Penghakiman Hakim Bicara dimuka surat 117-128 Rekod Rayuan pula, kami mendapati Hakim Bicara juga tidak terkhilaf apabila membuat dapatan anak pertama dan anak kedua sudah tidak termasuk dalam kategori kanak-kanak yang memerlukan penjagaan kerana telah mencapai umur dewasa. Kedua-dua anak tersebut masing-masing telah berumur 19 dan 18 tahun semasa kes dibicarakan, maka mereka sudah tidak terikat sebagaimana kehendak seksyen 85(2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[9] Hakim Bicara juga telah memerintahkan hak lawatan dan bermalam diberikan kepada Perayu termasuk cuti perayaan secara bergilir-gilir apabila memberikan hak penjagaan kepada Responden. Oleh sebab itu kami bersetuju bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf dan telah meraikan keterangan dan tuntutan pihak-pihak sebelum membuat perintah hak penjagaan tersebut termasuk Tuntutan Balas Perayu.

[10] **Merujuk kepada alasan rayuan kedua**, Perayu berhujah bahawa Hakim Bicara telah berpegang pada temuduga anak-anak tersebut sahaja tanpa diadakan perbicaraan secara menyeluruh pada setiap isu sebelum perintah dikeluarkan, maka sudah semestinya ia tidak akan mendatangkan keadilan terhadap diri Perayu. Ini adalah bertentangan dengan kehendak hukum Syarak dan undang-undang.

[11] Menurut Perayu lagi, Hakim Bicara sepatutnya tidak menerima sepenuhnya pilihan yang telah dibuat oleh anak-anak tersebut untuk tinggal bersama siapa sebaliknya memberi perhatian berdasarkan situasi dan keperluan serta kebajikan anak-anak tersebut walaupun anak-anak tersebut telah membuat pilihan sendiri. Perayu berhujah dengan merujuk kepada pandangan *Imam Ibnu Qayyim* di dalam kitab *Zaadul Ma'ad jilid 5, muka surat 2004-2005* (rujuk hujah penuh Perayu di muka surat 8).

[12] Responden dalam menjawab hujah Perayu menegaskan bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam berpegang dan membuat keputusan berdasarkan keterangan dan keputusan anak-anak tersebut. Menurut Responden lagi semasa keterangan diambil, anak-anak tersebut masing-masing telah berumur 17 tahun dan 12 tahun, maka menurut Responden yang dakwaan Perayu telah berlaku

kekehilafan berdasarkan pilihan anak adalah tidak betul. Kedua-dua anak telah mumaiyiz maka anak-anak tersebut berhak untuk membuat keputusan dalam memilih untuk tinggal dengan siapa. Ini kerana pada waktu keterangan anak-anak tersebut diambil, mereka telahpun mencapai umur mumaiyiz. Maka tidak menjadi permasalahan sekiranya Mahkamah mengambil kira pilihan anak-anak tersebut.

[13] Dalam memutuskan isu ini, kami telah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara dimuka surat 116-128 Rekod Rayuan. Kami mendapati bahawa Hakim Bicara telah mengulas berkaitan kewajaran anak membuat pilihan di perenggan 15-21 Alasan Penghakimannya. Seterusnya Hakim Bicara telah menyatakan dapatannya:-

“... berdasarkan peruntukan dan autoriti-autoriti di atas, Mahkamah berpandangan bahawa konsep pilihan anak juga terpakai bagi situasi kes ini memandangkan anak ketiga dan anak keempat telah mencapai umur mumaiyiz. Oleh yang demikian anak-anak tersebut wajar dipanggil dan diberi peluang membuat pilihan samada untuk memilih tinggal dengan ibu kandungnya (Plaintif) atau bapa kandungnya (Defendan).”

“... Mahkamah berpandangan bahawa pilihan anak ketiga dan keempat untuk tinggal bersama Plaintif boleh diterima oleh Mahkamah...”

Berdasarkan ulasan di atas, kami dapati Hakim Bicara telah berpuas hati dengan sesi temu bual bersama anak-anak tersebut dan mengesahkan bahawa anak-anak tersebut telah mumaiyiz.

[14] Selanjutnya kami dapati berdasarkan catatan perbicaraan bertarikh 8/4/2019 dan 12/6/2019 di muka surat 107-109 Rekod Rayuan, bahawa Perayu dan Responden telah memberikan keterangan semasa perbicaraan di Mahkamah

Bicara. Oleh yang demikian, dengan hormatnya kami mengatakan bahawa dakwaan Perayu bahawa prosiding kes tuntutan hak jagaan ini diteruskan dengan hujahan tanpa mengambil keterangan pihak-pihak adalah menyimpang dan tidak betul. Kami mendapati bahawa kedua-dua pihak iaitu Perayu dan Responden telah memberi keterangan masing-masing, malah Perayu juga telah mengemukakan saksi bagi menyokong kesnya. Oleh itu tidak timbul sama sekali Hakim Bicara tidak mengambil keterangan dalam kes tuntutan hak jagaan ini.

[15] Kami berpuas hati bahawa Hakim Bicara telah mengendalikan perbicaraan kes berdasarkan seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, dan keputusan Hakim Bicara memanggil anak-anak tersebut untuk menyatakan pilihan mereka juga adalah bertepatan dengan kehendak seksyen 85 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[16] Setelah mengesahkan anak-anak tersebut mumaiyiz, adakah perlu bagi Mahkamah menyelidik secara lebih mendalam sebab dan alasan kenapa mereka membuat pilihan untuk tinggal bersama ibu atau bapa. Sebelum menjawab persoalan ini ada baiknya kami jelaskan pengertian mumaiyiz berdasarkan pendapat fuqaha. Dr. Wahbah al-Zuhaili, dalam Fiqh dan Perundangan Islam (terjemahan), Jilid IV, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1996, halaman 126 menjelaskan :-

Mumaiyiz ialah peringkat di mana kanak-kanak sudah boleh membezakan di antara yang baik dengan yang buruk dan di antara yang memberi faedah dengan yang memberi mudarat, serta dia dapat memahami makna ungkapan-ungkapan ayat secara umum. Umpamanya dia memahami makna “jual” itu sebagai melepaskan harta dan makna “beli” ialah mendapat milik.

[17] Peringkat mumaiyiz bermula apabila umur seseorang kanak-kanak itu genap tujuh tahun kerana mulai umur tersebut barulah terdapat pada dirinya sifat *tamyiz*. Para fuqaha telah menetapkan bahawa umur minimum wujudnya sifat *tamyiz* ialah tujuh tahun (Rujuk Kitab Muhgni al Muntaj oleh Syarbini 3/254, Nihayah al Muhtaj oleh al Ramli 7/231, Hasyiah al Jamal oleh al Syeikh Sulaiman al Jamal 4/516).

[18] Apabila kanak-kanak tersebut telah mencapai peringkat mumaiyiz maka sifat penting yang ada pada dirinya ialah boleh membezakan di antara mana yang baik dengan mana yang buruk termasuk kebajikan mereka. Oleh itu apa jua keputusannya berkaitan pilihannya sama ada hendak tinggal dengan ibu atau bapa adalah diterima tanpa Mahkamah perlu mempersoalkan dengan lebih mendalam kerana kanak-kanak tersebut telah mempunyai sifat *tamyiz*. Hak mereka membuat pilihan juga jelas diperuntukkan dalam seksyen 85(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

(2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya

[19] Selain daripada itu kami juga mendapati Hakim Bicara telah mengulas berkaitan keharusan Mahkamah mendengar pilihan kanak-kanak yang telah mumaiyiz berdasarkan pandangan hukum Syarak di perenggan 15-18 Alasan Penghakiman. Antaranya kami perturunkan semula petikan di dalam kitab al Umm, oleh Imam al-Shafie, Juzuk 5, halaman 99, Beyrut, Lebanon yang menyatakan:-

[قال الشافعي]:

فاذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها مالم تتزوج وماكانوا صغارا فاذا بلغ أحدهم سبعا أو ثمانا سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما اختار

Maksudnya:

“Apabila berpisah kedua ibu bapa dan kedua-duanya berada dalam satu qariah yang sama maka ibu adalah lebih berhak terhadap anaknya selama ia belum berkahwin lain dan semasa anak-anak itu masih kecil. Apabila genap umur mereka tujuh tahun atau lapan tahun dan mereka sempurna akal, mereka disuruh memilih di antara bapa atau ibunya dan mereka akan bersama dengan siapa yang dipilih.”

[20] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa Hakim Bicara telah tidak terkhilaf apabila membuat keputusan berdasarkan pilihan anak-anak tersebut untuk tinggal bersama ibunya memandangkan kedua-dua anak tersebut telah mencapai umur kecerdikan (*mumaiyyiz*) sebagaimana yang telah digariskan oleh Syarak dan undang-undang. Pilihan anak-anak tersebut adalah menjadi keputusan kerana ketika itu anak-anak tersebut telah mencapai umur yang dapat menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.

[21] **Merujuk kepada alasan rayuan ketiga**, Perayu berhujah bahawa Hakim Bicara membacakan keputusan tanpa mengambil kira permohonan semakan oleh Perayu, sedangkan dalam prosiding tersebut keterangan Perayu telah diperintahkan dibatalkan oleh Hakim Bicara dan mengarahkan hujahan pihak-pihak dimasukkan.

[22] Responden dalam menjawab isu ini berhujah bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak mengambil kira permohonan semakan terhadap prosiding

kes ini kerana permohonan semakan Perayu terhadap tuntutan hadhanah ini dibuat pada 11/11/2019 iaitu dua hari sebelum kes tuntutan hak jagaan ini diputuskan.

[23] Dalam isu ini, dapatan kami bahawa keputusan kes tuntutan hak jagaan ini telah diputuskan terlebih dahulu iaitu pada 13/11/2019 sebelum keputusan semakan dikeluarkan pada 9/6/2020. Untuk isu ini juga kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara.

[24] Walau bagaimanapun dalam kes semakan antara Perayu dan Responden ini, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah menolak permohonan tersebut kerana tiada kekekhilafan Hakim Bicara semasa mengendalikan perbicaraan kes hak jagaan tersebut. Oleh itu alasan rayuan ketiga Perayu juga tidak dapat kami pertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan setelah mendengar dan meneliti hujahan kedua-dua belah pihak, **MAKA** kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

[1] Rayuan Perayu ditolak.

[2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes no. 10200-028-0702-2018 pada 13/11/2019 adalah dikekalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



-
1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor